

1500467-68.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... pandêmico", o afastamento do "tráfico-privilegiado" e a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defesa, às fls. 399/410 pleiteou, em síntese, pela absolvição por falha no arcabouço probatório no tocante a ambos os delitos, ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, ou, em caráter subsidiário, a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

É o breve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500467-68.2020.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500467-68.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114359/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 11326902 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 7415/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2114359 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7415/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Luciano Aparecido Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 286 "caput" do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 10 de maio de 2020, às 09h, na Rua Rosângela Vieira M. Carvalho, 2-2, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com

quatro eppenderfs ou 0,44 g de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto, incitou, publicamente, a prática de crimes de desobediência, resistência e fuga.

Boletim de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição/apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação preliminar (fls. 23/26) e laudo definitivo (fls. 125/128).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise formal do ato (fls. 73/88), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 106/109 foi recebida a denúncia e determinada a notificação e citação dos acusados.

O réu foi formalmente citado (fls. 130), tendo ofertado defesa preliminar (fls. 135/136).

Na decisão de fls. 142/143, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 193/195 foi ouvida a testemunha PM Douglas Marcio Assis Soares e deferido o pedido defensivo para oitiva da testemunha Wesley (em substituição à Marcelo).

Na audiência em continuação de fls. 256/259, foi ouvida a testemunha Wesley Ribeiro de Carvalho e revogada a prisão preventiva do acusado, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Na audiência de fls. 317/319, foi ouvida a testemunha Rafael Henrique Santos.

Por fim, na audiência de fls. 371/373, foi ouvida a testemunha Marcelo Ribeiro de Carvalho e interrogado o acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 378/385 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a valoração do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o reconhecimento dos antecedentes criminais do acusado, a constatação da reincidência específica e da agravante do “estado pandêmico”, o afastamento do “tráfico-privilegiado” e a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defesa, às fls. 399/410 pleiteou, em síntese, pela absolvição por falha no arcabouço probatório no tocante a ambos os delitos, ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, ou, em caráter subsidiário, a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade dos crimes está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição/apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação preliminar (fls. 23/26) e laudo definitivo (fls. 125/128).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O policial militar Douglas Marcio Assis Soares, na fase judicial (mídia SAJ) disse que estava em patrulhamento com o seu parceiro quando viu o acusado com o senhor Marcelo. Afirmou que o acusado começou a incitar os populares para “virem para cima da polícia”. Informou que a população se aproximou e hostilizou a equipe.

Esclareceu que o senhor Rafael também tentou hostilizar a equipe e tentou filmar a abordagem. Mencionou que a droga encontrada com o acusado era a mesma encontrada com o senhor Marcelo. Citou que a ocorrência aconteceu por volta das 8h. Asseverou que com o acusado tinha 30 reais em dinheiro e uma pedra de crack. Disse que até crianças apareceram com pedras para atacar a polícia. Afirmou que viu um veículo modelo palio na cor verde próximo ao réu, mas não detectou se houve a troca de algo, pois estava a uma distância de 100 metros, aproximadamente. Informou que não conseguiram acessar as filmagens realizadas pelo senhor Rafael.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: “Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha”.

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS

ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O informante Wesley Ribeiro de Carvalho, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ) disse, em resumo, que era no período da manhã quando um vizinho o chamou, avisando que seu irmão estava sendo agredido pelos PMs na quadra debaixo de sua residência. Afirmou que, quando chegou no local, viu os dois policiais muito alterados. Informou que não viu seu irmão praticando crime de resistência contra os policiais. Esclareceu que, no bairro, há vários pontos de vendas de drogas. Mencionou que seu irmão é apenas usuário de 'crack' e cocaína, por isso veio de Campinas para Bauru, visando a largar o vício. Citou que o rapaz que estava junto com o seu irmão, o senhor Marcelo, vulgo "Japa", tinha dinheiro e várias passagens em clínicas para tratamento do vício em drogas. Asseverou que sua esposa estava junto com seus filhos, que são crianças e que o Rafael (testemunha de defesa) estava filmando a ação dos policiais e as agressões que foram feitas. Disse que quando perguntou aos policiais o que estava ocorrendo, foi agredido física e verbalmente. Alegou que levou uma coronhada na cabeça, o que provocou revolta nos populares e, conseqüentemente, o tumulto durante a abordagem policial.

A testemunha Marcelo Ribeiro de Carvalho, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse, em síntese, que, no momento da abordagem policial, tinha ido buscar entorpecentes para Luciano e para ele. Afirmou que, quando foram abordados, os policiais os colocaram dentro da viatura e os levaram para um local, próximo de um viaduto, onde os policiais militares disseram que Marcelo estaria vendendo, mas ele disse que apenas comprou drogas para Luciano e ele consumirem. Informou que os policiais disseram que imputariam o crime ao acusado Luciano, por ele ser de Campinas. Esclareceu que o acusado apenas deu o dinheiro para a compra dos entorpecentes. Mencionou que comprou 05 porções de 'crack', no valor de R\$ 5,00 cada e que o réu lhe deu R\$10,00 e que foi obrigado pelos policiais a dizer que comprou a droga do acusado. Citou que já conhecia o réu do bairro.

A testemunha Rafael Henrique Santos, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse que o acusado não é traficante e que a droga encontrada era para seu uso pessoal. Alegou que o tumulto ocorrido foi devido à violência policial na abordagem. Informou que foi algemado pelos policiais por pensarem que ele estivesse filmando a ocorrência. Esclareceu que viu o acusado sendo agredido pelos policiais militares.

O acusado Luciano sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse é usuário de drogas e que o ponto de drogas onde foi preso fica na rua detrás da residência do seu irmão. Alegou que foi até o local conhecido por ser ponto de venda de drogas

para comprar crack, quando encontrou um rapaz "japonês". Informou que deu dinheiro para que ele comprasse a droga e ficou aguardando. Esclareceu que este rapaz retornou com uma pedra de 'crack' e, quando foi pegá-la, a viatura policial se aproximou. Mencionou que os policiais militares já iniciaram a abordagem de maneira violenta. Citou que chegou a sofrer socos na região do abdômen que começou a gritar por socorro, quando seu irmão ouviu seus gritos e veio socorrê-lo. Asseverou que pensou que iria morrer, sendo que um outro policial começou a agredir seu irmão com coronhadas na cabeça, quando seus sobrinhos (crianças pequenas) foram defender o pai. Disse que os populares se revoltaram com a polícia devido à sua abordagem violenta. Alegou que não incitou que os populares fossem contra a polícia, porém eles ficaram revoltados com tamanha violência policial. Informou que Marcelo mencionou que os próprios policiais militares o orientaram a dizer que ele traficava.

Pela prova colhida, de rigor a condenação pelos delitos imputados.

Os depoimentos dos policiais, em ambas as fases, foram uníssonos.

A testemunha Marcelo, assim mencionou na seara inquisitiva (fls. 11/12): " (...) QUE NESTA MANHÃ FOI ATÉ A FAVELA DO JARDIM IVONE A FIM DE COMPRAR CRACK E FOI, ENTÃO, EM UM LOCAL DE COSTUME ONDE ADQUIRE A DROGA; QUE CHEGANDO LÁ ENCONTROU UM INDIVÍDUO DE COR NEGRA E SE APROXIMOU E PERGUNTOU ONDE TINHA "PEDRA", QUERENDO REFERIR-SE A CRACK; QUE TAL INDIVÍDUO DISSE QUE TINHA PARA VENDER; QUE PEDIU TRÊS PEDRAS E O INDIVÍDUO DE IMEDIATO PEDIU O DINHEIRO PARA SÓ DEPOIS FORNECER A DROGA, O QUE É NORMAL NAS "BIQUEIRAS"; QUE DEU R\$ 30,00 PARA O INDIVÍDUO, SENDO UMA NOTA E R\$ 20,00 E UMA DE R\$ 10,00; QUE O INDIVÍDUO ENTÃO PEGOU TRÊS PORÇÕES DE DROGA, QUE ESTAVAM SEPARADAS E ACONDICIONADAS EM SAQUINHOS PLÁSTICOS ZIP LOC E OS ENTREGOU; QUE ASSIM QUE ESTAVA RECEBENDO AS PORÇÕES DE DROGA UMA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PAROU E IMEDIATAMENTE OS ABORDOU; (...) QUE EM SEGUIDA REVISTARAM O TRAFICANTE E ACABARAM ENCONTRANDO OS VALORES QUE HAVIA PAGO PELA DROGA QUE HAVIA ACABADO DE COMPRAR DELE, FOI QUANDO ANTES MESMO DO TÉRMINO DA REVISTA PESSOAL EM TAL INDIVÍDUO VÁRIAS PESSOAS CHEGARAM NO LOCAL, CERCARAM OS POLICIAIS E HOUVE INÍCIO UMA BRIGA GENERALIZADA, FOI QUANDO VIU QUE O TRAFICANTE PASSOU A JOGAR ALGO LONGE, QUE OS POLICIAIS FICARAM OS SEGURANDO JUNTO A PAREDE E SE DEFENDENDO DOS INSULTOS E AGRESSÕES; (...) QUE NESTA OPORTUNIDADE RECONHECE O TRAFICANTE QUE LHE FORNECEU AS PORÇÕES DE DROGAS COMO SENDO LUCIANO APARECIDO DA SILVA, QUE FOI DETIDO E NESTE PLANTÃO POLICIAL O RECONHECEU FORMALMENTE EM SALA PARA RECONHECIMENTO DE PESSOAS"; (g.n.)

Do depoimento, possível extrair que a testemunha foi comprar droga do acusado, sendo que, com ele (acusado), foi apreendida justamente a quantia em dinheiro dada pelo depoente (R\$ 30,00).

Aliás, o próprio miliciano, em Juízo, disse que a droga apreendida com o acusado e a de Marcelo eram da mesma natureza.

Além disso, viu o acusado jogando algo longe, tendo o reconhecido, como traficante.

Depois, a testemunha Wesley, também na fase inquisitiva (fls. 14), asseverou:

" (...) ATÉ PORQUE JÁ ESTAVA UM TUMULTO NO LOCAL, FOI QUANDO COMEÇARAM A XINGAR E A AGREDIR OS POLICIAIS; QUE ACABOU PARTINDO PARA CIMA DOS POLICIAIS TAMBÉM, TENDO SIDO AGREDIDO COM UMA CORONHADA NA CABEÇA (...)";

Em outras palavras, diversamente do alegado em Juízo, os policiais apenas se defenderam (já que eram xingados e agredidos) e, além disso, Wesley "partiu para cima", sendo que, inclusive, as eventuais "coronhadas" jamais foram comprovadas. Ou seja, os depoimentos são contraditórios.

Em arremate, o acusado disse também perante a D. Autoridade Policial (fls. 15/16): " (...) QUE NESTA MANHÃ SAIU DA CASA E SEU IRMÃO E PASSOU A CAMINHAR PELA RUA, FOI QUANDO ENCONTROU UM INDIVÍDUO QUE SE APROXIMOU PARA CONVERSAR E APENAS PEDIU EMPRESTADO UM ISQUEIRO PARA ACENDER UM CIGARRO; QUE NO MOMENTO EM QUE ENTREGAVA O ISQUEIRO DE VOLTA AO DONO FOI ABORDADO PELOS POLICIAIS MILITARES JUNTAMENTE COM O DESCONHECIDO";

É dizer, apenas em Juízo mencionou que era consumidor de 'crack', com o que, estranhamente, também unicamente em Juízo, foi corroborado pelo irmão.

Aliás, ne, sequer o acusado respondeu ao pregressamento (fls. 34), quando poderia delinear eventual vício, jamais delineado.

Outra contradição, ocorrida também na seara inquisitiva é que, enquanto o acusado disse que entrega panfletos para uma pizzaria, recebendo R\$ 50,00 por dia, o irmão disse que ele é ajudante geral.

Portanto, a licitude do numerário não restou evidenciada.

Além disso, o acusado é reincidente pelo delito de tráfico (feito nº 15930-22.2014, fls. 64/68), o que, comprova a infração penal hedionda, além de, em razão da natureza do entorpecente (crack), denota que a droga não era destinada para o consumo próprio, nos termos do art. 28, §2º da Lei Antidrogas.

Além disto, o policial, em Juízo, mencionou: "Afirmou que o acusado começou a incitar os populares para "virem para cima da polícia".

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos imputados na denúncia.

Passo à fixação da pena.

Crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (crack), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto porque, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015).

Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, o acusado é reincidente específico, o que permite maior agravação (1/5).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 4. CAUSAS DE AUMENTO. CRIME PERTO DE ESCOLA E COM ADOLESCENTE. PLEITO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3. As circunstâncias judiciais bem como as agravantes e atenuantes não possuem patamares fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de elevação a critério do magistrado, desde que observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando a balizar um critério razoável, assentou que seria adequada uma elevação que não fosse superior 1/6 (um sexto). No entanto, cuidando-se de réu multirreincidente ou reincidente específico, revela-se escorreita a agravação da pena em patamar maior, uma vez que devidamente motivada em elemento concreto dos autos. Portanto, não há qualquer ilegalidade no agravamento da pena em 1/5 (um quinto) em virtude de o réu ser reincidente específico.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 282148 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/05/2016)

Assim, a pena deve ser agravada em 1/5, atingindo 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) diárias.

Ainda na fase intermediária, quanto à agravante do “estado pandêmico” deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o acusado é reincidente específico.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, por que o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 “caput” do Código Penal, e, ressalvadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o

próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Por isso, a pena atingida na segunda fase é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

O réu Luciano é reincidente específico.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme

dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

Crimes previsto no art. 286 do CP.

Crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Desta feita, fixo a pena em 03 meses de detenção.

Na segunda fase, sem atenuantes. Presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual elevo a pena em 1/5 e a tenho em: 03 meses e 18 dias de detenção.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno a sanção definitiva.

Tendo em vista se tratar de réu reincidente, fixo do regime semiaberto para o cumprimento de pena, a fim de atender às finalidades da reprimenda, quais sejam, preventiva e repressiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL para:

CONDENAR o réu Luciano Aparecido da Silva, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

CONDENAR o réu Luciano Aparecido da Silva, já qualificado nos autos, à pena de 03 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 286, "caput" do Código Penal.

O réu responde ao processo em liberdade e assim poderá recorrer, ante a imposição de cautelares, as quais devem ser mantidas no presente momento.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/22. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto ao aparelho celular e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA